

1500166-20.2022.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... tese de nulidade.

Da Imputação do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Wellington Flávio Santos Santana

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-20.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-20.2022.8.26.0605

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108716/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 24446932 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2108716 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON FLAVIO SANTOS SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra WELLINGTON FLÁVIO SANTOS SANTANA.

Na denúncia, narra-se que no dia 20 de abril de 2022, por volta das 22h50min, nas proximidades do Supermercado Proença, situado na Avenida Brasil Norte, nº 506, Zona Norte, e na residência situada no Passeio Recife, nº 312, Zona Norte, ambos nesta cidade e comarca de Ilha Solteira/SP, Wellington Flavio Santos Santana, qualificado às fls. 05, agindo de forma livre e consciente, trouxe consigo e guardou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", com peso total aproximado de 32 g (trinta e dois gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação preliminar de fls. 19 e foto de fls. 18 e laudos toxicológicos de fls. 103/105 e 106/108.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 46/47).

Os laudos de constatação provisória e definitiva tiveram resultado positivo para maconha (fls. 19 e 103/105).

Notificado pessoalmente (fl. 133), o réu ofereceu defesa escrita (fls. 150/158).

Recebida a denúncia em 08/07/2022 (fls. 159/160).

No curso da instrução (fls. 196/197), realizou-se oitiva em audiência de uma testemunhas, da informante e do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas. .

Folha de Antecedentes Penais (fls. 36 e 37) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 38 e 39).

É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar de Nulidade - Violação de Domicílio

Inicialmente, observo que não prospera a preliminar de nulidade das provas colhidas.

No RE 603616, Tema 280 da Repercussão Geral, o STF, em decisão paradigmática, estabeleceu:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de

flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é

aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição

não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da

Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a

medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da

garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa

Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais

de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o

direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que

havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado

judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso

concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) (destaquei)

A jurisprudência do STJ tem extraído do acórdão paradigma que: (i) "(0) ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da

existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 671.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021); e (ii) "(A) fere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência" (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por primeiro, insta salientar que houve denúncia anônima (fl. 15).

No mais, os policiais somente procederam à busca pessoal diante da atitude suspeita do réu a qual, no caso, caracterizou-se pela conduta do réu que, ao avistar os policiais, jogou no chão uma porção que trazia em sua mão.

Tendo realizado a busca pessoal, indagaram o acusado se ele possuía outras drogas em sua casa, ao que respondeu que sim.

Confessou para os policiais, pois provido de consciência. E a consciência, diante da flagrância, quer expiar a culpa que sobre ela recai: mecanismo psíquico de auto-preservação moral.

Dizer que a confissão frente aos policiais não é válida diante de suposto temor que se sente perante a autoridade nada mais traduz do que hipótese, dependente de prova empírica, a qual não foi feita.

Pese não tenha sido lido o aviso de miranda, certo é que a entrada na residência, segundo o relato dos policiais, foi franqueada pela genitora do réu, não havendo nos autos elementos de convicção de que ela fora coagida de qualquer forma.

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente:

"- A condenação do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes não se fundou, exclusivamente, em denúncia anônima, mas nas circunstâncias do flagrante, na sua confissão extrajudicial, relatada pelos flagranteantes, e nos depoimentos dos agentes policiais condutores da prisão, confirmados em juízo. De fato, consignou-se que os policiais encontraram, em terreno abandonado, por indicação do próprio agravante, que confessou a prática do delito para os agentes, grande quantidade de material entorpecente acondicionado para venda, cuja origem também foi informada pelo flagranteado, bem como localizaram uma balança de precisão.

- Não estando a condenação do agravante escudada apenas em delação de pessoa não identificada, como se percebe da simples leitura dos títulos judiciais, e havendo, ademais, prova submetida ao contraditório judicial para sustentar o juízo condenatório, o debate relativo à suficiência do acervo probatório amealhado não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ.

(AgRg no HC 658.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)"

Observe, por oportuno, que a decisão proferida no HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021, foi anulada por decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.342.077, a qual assentou:

"(...) a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País – estaduais, distrital e federal – verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação, como se verifica nos itens 7.2, 12 e 13 da Ementa do referido julgado:

'7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em

vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. (...)

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.'

(...)

Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE

Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) (...)."

Com efeito, nada há nos autos a respaldar a tese de violação de domicílio, o que macularia as provas produzidas, razão pela qual afasto a respectiva tese de nulidade.

Da Imputação do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Wellington Flávio Santos Santana

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conclui-se que o crime pode restar configurado ainda que a alienação

da droga se dê gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo de análise do tipo penal, deve-se observar que a lei não exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em seu Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

"Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (Dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir)."

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como tetraidrocanabinol, definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão (fls. 16/17) e a prova oral produzida em juízo provam que

estava na posse do réu.

Em juízo, a testemunha Alexsandro Coutinho dos Santos, policial militar, declarou que: em patrulhamento avistaram o réu pela Avenida Brasil. O acusado, ao avistar a viatura, soltou algo ao solo. Decidiram abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Entretanto, há aproximadamente 5 ou 6 metros localizaram os entorpecentes envolvido por um plástico do tipo ziplock. Posteriormente foram a residência do réu e, com a entrada franqueada pela mãe do acusado, encontraram mais porções de droga em seu quarto, sendo que os entorpecentes localizados também estavam envolvidos no plástico do tipo Ziplock. Localizaram, ainda, uma tesoura com resquícios de entorpecente. Não conhece a escolar Arno Hausser, muito menos sabe o período de funcionamento.

A testemunha Maria de Lourdes Santos Santana, genitora do acusado, declarou que: o Welington não faz uso de drogas dentro da residência. Não é comum que o filho guarde entorpecentes em casa, porém já encontrou uma porção de droga em seus pertences. Enfatiza que Welington é usuário de maconha e que trabalha como cabeleireiro e servente de pedreiro. Não autorizou a entrada dos policiais em sua residência durante a abordagem, todavia, assinou "um papel" a pedido dos agentes policiais.

O acusado Welington Flavio Santos Santana, declarou que: foi abordado na Avenida Brasil, entretanto foi levado pelos agentes a uma rua próximo a sua residência. No local, os milicianos disseram que ninguém estava vendo e que ele deveria indicar onde estava a droga. Nega a propriedade das nove porções de droga encontrada, dizendo que seu entorpecente (porção única) estava embalado em uma "sacola de mercado". Não tem nada contra os policiais. Conhece o PM Fernandes. Asseverou que, na oportunidade de sua audiência de custódia, não indicou nenhuma violência ou coação policial por desconhecimento.

Em seu interrogatório, o(a) ré(u), narrou que tinha apenas uma porção consigo para uso próprio, insinuando que as demais drogas foram plantadas em sua residência. Em suporte a seus relatos, não produziu qualquer prova.

Por isso, merece maior crédito a narrativa policial, desprovida de incoerências e de suspeita de interesse dos militares na causa (não há razão para acusarem injustamente os réus).

Assim, a prova produzida ao longo da instrução criminal, não dá margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, porque angariada com elementos seguros. Não se viu nenhum indício de que evidencie a insinceridade, justifica sua recusa, pelo contrário, representa dados relevantíssimos na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

No caso, a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão (droga apreendida com tesoura com resquícios da droga), a forma de acondicionamento da droga (entorpecentes envoltos em saco tipo "ZipLock"), a apreensão de numerários e as denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico. Anoto ser ponto pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido (HC 461377/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; EDcl no HC 463656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 24/10/2018).

Por todos, veja-se o seguinte precedente do STF:

"HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO

PROCESSUAL - IRREGULARIDADE - CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA - AFERIÇÃO - JUÍZO. A competência há de ser aferida considerando o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA - REPERCUSSÃO - AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal. TRÁFICO DE DROGAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)"

No mais, como alhures asseverado, o caso, há elementos seguros que demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico e não o de posse de drogas para consumo, razão pela qual afasto o pedido desclassificatório.

Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes.

Incide a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP)/ senilidade (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que na data do fato, 21/04/2022, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos.

De outro giro, não há como reconhecer a causa de aumento da pena contida no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Com efeito, trata-se de causa de aumento de natureza objetiva (AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022), sendo certo que a infração foi praticada nas imediações de diversos estabelecimentos de ensino (laudo de fls. 98/102). Contudo, não há falar em incidência da majorante, quando o estabelecimento de ensino estiver fora de funcionamento (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). E, pelo horário em que praticada a infração, tenho que a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estivessem funcionando às 22h50m daquele dia.

Dispõe o art. 33, §4º, da Lei

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre a figura do tráfico privilegiado, cumpre firmar, desde já, algumas premissas, colhidas da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

(i) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017, DJe 04/10/2017);

(ii) a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j.m 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

(iii) é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de

que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (REsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

(iv) é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa (AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2019, DJe 02/08/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2019, DJe 24/05/2019);

(v) diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito (HC 477280/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; HC 458735/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 23/10/2018);

(vi) as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Repercussão Geral Tema 712). Assim, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem (AgRg no HC 497047/SP, Rel. Min. Rogério Scchietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2019, DJe 25/06/2019; HC 472052/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

(vii) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF (HC 510248/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 13/06/2019; HC 491328/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 01/07/2019);

(viii) reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistirá óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; HC 482626/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2019, DJe 09/04/2019); e

(ix) o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600; AgRg no HC 485746/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no HC 485237/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No presente caso, tem-se que o réu é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes. Contudo, já respondeu, no âmbito infracional, por fato análogo ao tráfico de drogas (Pr. 1501640-41.2019.8.26.0246), donde a prova de que faz do tráfico seu meio de vida desde há muito tempo (fl. 39).

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Sr. Wellington Flávio Santos Santana praticou o delito de Tráfico de Drogas, devendo ser responsabilizado penalmente pelas suas condutas.

III - FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Wellington

Flávio Santos Santana.

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11.343/06), deve ser observado que a natureza e a quantidade da substância apreendida. Tenho que a natureza da droga não é das mais deletérias; lado outro, a quantidade foi utilizada para fundamentar o afastamento da redutora, razão pela qual não pode ser utilizada como circunstância judicial. No mais, tem-se que:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumpr, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo

sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe. 21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020).

Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fl. 36) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fl. 38/39) da parte ré, não se constata nenhuma condenação definitiva por infração praticada antes desta em julgamento. Assim, os antecedentes devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos, ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são

morais/imorais ou sociais/antissociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento. As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) O crime em questão é classificado doutrinariamente como delito vago, isto é, conquanto o Estado seja considerado uma vítima indireta, não há nenhuma vítima direta definida, razão pela qual não se cogita do comportamento da vítima para a produção do resultado delitivo.

Para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, utilizo a fração de 1/8, filiando-me ao recente precedente do STJ:

"4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

(AgRg nos EDcl no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)"

Não havendo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base fica fixada no mínimo legal, isto é 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes.

ii) Incide a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP)/ senilidade (art. 65, inc. I, do CP).

Em que pese a incidência das circunstâncias atenuantes, deixa-se de minorar a pena, pois na segunda-fase não se permite a fixação de pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231-STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".)

Para a valoração das agravantes e das atenuantes, valho-me da fração de 1/6 (STF - HC: 69392 SP, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/1992, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 12-03-1993 PP-03560 EMENT VOL-01695-03 PP-00610).

Não havendo quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, a pena-intermediária fica fixada no mesmo patamar da pena-base, isto é 5 anos e dias de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas; e

ii) Não incide a causa de diminuição do tráfico “privilegiado”.

Não incidentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição, a pena fica finalmente arbitrada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Valor do Dia-Multa

Fixo o valor da dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), uma vez que não há nos autos dados suficientes à análise exauriente da situação econômica da parte ré (art. 60, caput, do CP).

Detração

Deixo de efetuar a detração (art. 42 do CP), como manda o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes informações suficientes sobre imposição e cumprimento de penas privativas de liberdade por outros crimes (art. 111 da LEP).

Regime Inicial de Cumprimento

Dispõe o art. 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir da aferição de quatro critérios: tipo de pena prevista para o tipo legal (reclusão ou detenção), quantidade de pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do CPP), sendo certo que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719-STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”), exigência essa não satisfeita pela mera menção à gravidade em abstrato do crime (Súmula 718-STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”).

No presente caso, tem-se que:

i) a pena ficou definitivamente fixada em 5 anos;

ii) a parte ré é primária;

iii) as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Portanto, entende-se como correto o estabelecimento do regime semi-aberto para o cumprimento inicial da pena.

Observe-se que o reconhecimento do tráfico privilegiado afasta a hediondez do crime. Todavia, ainda que assim não fosse, desde há muito que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos (STF, Plenário, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012).

Dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza do crime e quantidade de pena aplicada) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso, observada a exceção da recomendação social da medida, e ser suficiente a substituição).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Neste ponto, aliás, cumpre rememorar que, reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistiu óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Suspensão Condicional da Pena (Sursi)

Dispõe o art. 77 do CP:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a